

1501792-69.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

"Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 17h00min

Processo Digital 1501792-69.2022.8.26.0542 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501792-69.2022.8.26.0542

Controle: 2022/001579

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

EDILSON CESAR NUNES COELHO e MAXMILIANO MOURA RAMOS MORTAIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

MAXMILIANO MOURA RAMOS MORTAIS e EDILSON CÉSAR NUNES COELHO, qualificados nos autos, foram denunciados por incursos nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, em 28 de julho de 2022, por volta das 11h5min, na Rua Goiabeira, 40, Pestana, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, vendiam, traziam consigo e guardavam: 46 invólucros plásticos contendo 85,07g de maconha, 147 eppendorfs contendo 73,72g de cocaína, 70 invólucros plásticos contendo o peso líquido de 9,82g de crack e 43 invólucros plásticos contendo o peso líquido de 12,18g de cloreto de metileno, todas substâncias entorpecentes, capazes de determinar a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como, nas mesmas circunstâncias tempo-espaciais, associaram-se entre eles para o fim de praticarem o tráfico de drogas.

Apurou-se que diversas notícias anônimas foram registradas, dando conta de que no local havia comércio ilegal de drogas. Com a finalidade de averiguar as informações, policiais civis para lá se dirigiram e efetuaram campana velada. Eles, então, visualizaram Edilson César e Maximiliano em atividade típica de comercialização de drogas, sendo que, inicialmente eram abordados por transeuntes. Após Edilson César e Maximiliano adentravam um barraco abandonado existente no local, para logo em seguida retornarem com objeto em mãos, entregue aos transeuntes

e deles recebendo algo em troca.

Após essa dinâmica se repetir por algumas vezes, os agentes policiais decidiram efetuar a abordagem. Em revista pessoal encontraram uma porção de maconha no bolso de Maximiliano, ao passo que com Edilson César foi apreendida a quantia de R\$ 40,00, também em seu bolso.

Efetuada revista no barraco abandonado, em que Edilson César e Maximiliano entravam a cada venda, foi encontrado o restante da droga.

A denúncia foi ofertada, sendo notificados Maximiliano e Edilson César (fls. 166/167). Sobreveio a defesa preliminar defesa preliminar (fls. 173) e, não havendo causas de sumária absolvição, a denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2022 (fls. 387/388). Maximiliano e Edilson César foram citados (fls. 214 e 216).

Em instrução processual foram ouvidas testemunhas (fls. 219/220), prosseguindo-se com os interrogatórios dos acusados (fls. 221/222).

Em sede de memoriais escritos o Dr. Promotor de Justiça pleiteou pela procedência da ação penal e consequente condenação de Maximiliano e Edilson César nos termos da denúncia (fls. 226/235).

A Defesa, por sua vez, pugnou, para o artigo 35, da Lei 11.343/06, pela absolvição, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; pela absolvição de Edilson César e Maximiliano relativamente ao delito do artigo 33, da Lei 11.343/06, conforme artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06; e pela aplicação do § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06 (fls. 240/248).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

A materialidade delitiva se consubstancia auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fls. 9), laudo pericial de constatação (fls. 12/15) e laudo pericial químico-toxicológico (fls. 136/141), bem como pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório (fls. 219/220).

Perante a D. Autoridade Policial, Edilson César afirmou que estava na rua, juntamente com seu amigo Max, quando foram abordados por policiais. Conhecia Max fazia tempo, pois eram amigos de infância. Negou que estivesse traficando no local. Foi até ali para comprar drogas, pois era usuário (fls. 4). Maximiliano, por sua vez, declinou que estava na rua com seu amigo Edilson, quando foram abordados por policiais. Não estava traficando no local, sendo que foi ali comprar drogas, pois era usuário (fls. 5).

Em Juízo, Maximiliano afirmou ser usuário de crack e estava com dívida com traficantes. Foi ameaçado de morte e lhe foi oferecido traficar para quitar a dívida. Havia acabado de assumir o horário para início da venda de drogas. Edilson passou e não sabia que era o interrogando que estava vendendo. Ele saiu e voltou. Pediu drogas e ainda não tinha servido Edilson quando foram abordados. Não sabia da quantidade de drogas dentro do imóvel. A droga que estava vendendo estava no corredor ao lado daquele imóvel. Não estava com dinheiro. Não viu os policiais apreenderem dinheiro. Estava com metade de uma porção de cocaína. A droga que iria comercializar e que estava ao lado do imóvel não foi apreendida. Não informou aos policiais que estava vendendo drogas no local. Edilson não chegou a entrar no imóvel com o interrogando. Apenas foram até o corredor ao lado do imóvel. Mesmo trabalhando não tinha condições de quitar a dívida até porque pagava aluguel e essa dívida era alta. Usa crack há oito anos (fls. 221).

A parcial confissão de Maximiliano deve ser aceita naquilo que estiver amparada pelo conjunto probatório amealhado e afastada na esteira do que for contrariada, de acordo com a interpretação holística das provas.

A alegada coação irresistível ou estado de necessidade não restaram demonstrados, sendo inaplicável o reconhecimento da situação prevista pelo artigo 22 ou 24, do Código Penal.

Edilson César negou a prática delitiva. Declarou que estava desempregado há meses e era usuário de drogas desde 2018, quando faleceu sua mãe. Não conseguiu mais parar de usar entorpecente. No dia dos fatos, trabalhou retirando entulho e recebeu

oitenta reais. Separou cinquenta reais para comida. Morava em uma rua paralela ao local dos fatos e conhecia todo mundo. Foi até a biqueira uma primeira vez e não localizou ninguém vendendo ali. Foi até outra biqueira e comprou droga, mas era de péssima qualidade. Retornou para a biqueira e acabou vendo Maximiliano. Nunca tinha visto ele ali vendendo drogas. Outros usuários também estavam querendo saber quem estava vendendo ali. Subiu a viela para usar a porção que já tinha comprado de droga. Depois que fez o uso desceu e pediu mais drogas para Maximiliano. Quando foi abordado, estava sob efeito de drogas e tinha quarenta reais consigo. Terminou de cumprir pena em 2013. Chegou a ir atrás de Maximiliano até o imóvel que ele pegava droga, mas foi até a metade e isso para fazer o uso de entorpecente que já tinha pois havia crianças na rua.

Era usuário de cocaína e crack. Tentou várias vezes se internar, mas não obteve êxito (fls. 222).

A negativa de Edilson César não encontra respaldo no conjunto probatório amealhado, desmerecendo, portanto, guarida.

A testemunha Policial Civil Moises asseverou que o local já era conhecido como ponto de venda de entorpecente, vulgarmente chamado Biqueira Bolinha. No dia, houve informações de que Carol, loira, levaria drogas para serem comercializadas no local. Fizeram campana e, em um imóvel abandonado, que ficava em uma rua sem saída, observaram os acusados que entravam e saíam do imóvel e conversavam com pessoas com características de vendas de drogas. Depois deles terem feito atendimento e Carol não ter aparecido, fizeram a abordagem deles. Com Maximiliano foi apreendida uma porção de cocaína. Com Edilson houve a apreensão de quarenta reais. Eles negaram o comércio de entorpecente. No local que eles entravam foi localizada uma sacola contendo cocaína, pedra e lança-perfume.

Além dos dois, durante a campana, ninguém mais entrou nesse imóvel. Não identificaram o proprietário do imóvel, sendo que os abordados negaram o tráfico. Fizeram campana de quarenta minutos e viram eles atenderem duas pessoas. Estava com o policial Robson, seu parceiro. Filmaram em celular particular a atitude dos abordados. Foi o declarante quem fez as filmagens. Só havia os dois transeuntes na rua. Os dois ficavam conversando e atendiam as pessoas sendo que era Edilson que pegava o dinheiro da pessoa e entregava a droga. Maximiliano chegou a dizer que só entrou no local para consumir drogas. Os dois entravam no imóvel. Não havia bens pessoais dentro do imóvel só havia lixo e entulho, o imóvel era abandonado (fls. 219).

A testemunha Policial Civil Robson declinou que houve denúncia que pela manhã, até às 10h, uma loira viria do escadão entregar uma mochila cheia de drogas nessa rua. Fizeram campana e observaram os acusados que entravam em uma casa. Edilson entrava no local enquanto Maximiliano ficava olhando do lado de fora. Eles entregavam algo para alguém. Resolveram abordá-los. Nesta casa que eles entravam tinha lixo e localizaram aproximadamente 300 porções de droga. Maximiliano ficava olhando enquanto Edilson entrava, mas depois ele seguia Edilson.

Viu eles atendendo por duas vezes. Era um cruzamento e eles viravam à direita descendo. Perdia a visão deles. De onde estava podia ver o atendimento e eles entrando no imóvel. Quando eles foram abordados mencionaram que estavam entrando no local para usarem drogas. Com Maximiliano houve apreensão de metade de uma porção de cocaína. Com Edilson, pelo que se recordou, era apenas dinheiro, quarenta reais. A campana durou aproximadamente uma hora. Apenas os dois entraram no imóvel durante a campana. O policial Moises os filmou atendendo as pessoas. Apenas depois da abordagem algumas pessoas desceram e perguntavam do que se tratava. Identificaram-se e mostraram a droga. O imóvel estava com carniça e cheio de lixo sendo impossível ficar lá dentro para preservação. Tiraram foto e avisaram o Delegado. A droga foi localizada embaixo de um colchão e lixo, que ficava próximo da porta do banheiro. Pelo que notou, Edilson estava vendendo a droga e Maximiliano em apoio. O imóvel que eles entravam e saíam era o mesmo onde a droga foi apreendida sendo que foram abordados quando estavam saindo desse imóvel. Não havia pertences pessoais dentro do imóvel, apenas lixo (fls. 220).

Quanto ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, os testemunhos policiais demonstram a veracidade dos fatos, até porque responderam às indagações formuladas, apresentando

as mesmas circunstâncias, tanto no aspecto principal quanto no secundário, quer na fase extrajudicial como em Juízo. Ainda, encontram-se corroboradas pela parcial confissão judicial de Maximiliano.

É cediço que o testemunho policial não é afetado, positiva ou negativamente, pela função que exerce. A condição funcional não confere ao seu testemunho maior força persuasória e nem o inquina de suspeição. O valor probante de sua versão é aferido pelo mérito e de acordo com o grau de confiabilidade segundo a harmonia das provas coligidas aos autos. Neste sentido, vasta é a jurisprudência proclamada pela suficiência, se coesos os testemunhos policiais, para embasar o édito condenatório.

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhos, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial" (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Droga apreendida nas mãos dos apelantes - Grande quantidade - Policiais que se infiltraram na quadrilha afim de se passarem por traficantes - Prova colhida que aliada ao depoimento dos policiais que autorizam a condenação - Recurso não provido. É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V.U.).

As provas são uníssonas e coesas quanto à responsabilidade criminal de Maximiliano e Edilson César. Em campanha, decorrente de denúncia anônima, os agentes policiais visualizaram os acusados em atitude típica de mercancia, sendo que Maximiliano entregava algo às pessoas que faziam contato com eles, enquanto Edilson César recebia algo delas. Abordados, com Maximiliano foi encontrado entorpecente, e com Edilson César dinheiro. Ressalte-se que os policiais civis viram ambos se dirigindo ao imóvel, onde, posteriormente, foi localizado o restante do entorpecente.

Para caracterização do delito de tráfico ilícito de entorpecentes dever-se-á atender à natureza e a quantidade da substância entorpecente, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Seguindo essas variantes houve plena demonstração do animus de traficar, sendo robusto o material cognitivo.

Ora, os elementos citados são suficientes e indicam que o material tóxico apreendido se destinava ao comércio ilícito.

Maximiliano e Edilson César foram denunciados por venderem, trazerem consigo e guardarem entorpecente cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

"Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários, tais como a confissão extrajudicial, a quantidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes dos agentes, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciem a atividade delituosa" (TJRJ - ApCrim 5.492 in Direito Concreto, v. 5, p. 191).

"Desimporta se o agente não chegou a vender o tóxico, pois trazer consigo, já é delito consumado, segundo uma das normas múltiplas que contém o art. 12 da lei respectiva" (TJRS - AC 68.305.178-3 - Rel. Milton dos Santos Martins - RJTJRS 107/59).

Com esta prova a respeito da finalidade de entrega do entorpecente a consumo de terceiros não há que se cogitar da desclassificação para o delito preconizado no artigo 28, da Lei 11.343/06. Anote-se que a eventual condição de usuário não exclui a traficância.

Relativamente ao delito do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, não restou clara a associação e seus fins entre Maximiliano e Edilson César.

Não basta a mera narrativa dos policiais civis, de que um receberia o dinheiro dos usuários e o outro entregaria o entorpecente, não sendo suficiente a demonstrar a existência de liame subjetivo e objetivo estável entre eles.

Não há elementos nos autos que permitam concluir pela ocorrência da associação para fins de tráfico, posto que esta deve ser estável e permanente, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. MINORANTE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTO CONCRETO E IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando a expressão utilizada pelo legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas seja para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. As instâncias de origem dentro do seu livre convencimento motivado apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, de maneira que não há nenhuma ilegalidade manifesta tampouco ausência de fundamentação no ponto em que houve a condenação dos acusados pelo delito de associação para o narcotráfico. 3. Porque mantida a condenação dos acusados pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, não há como reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu favor. 4. A instância ordinária entendeu devida a imposição do modo inicial fechado com base nas “circunstâncias fáticas essenciais (Réus desocupados, presos em flagrante em poder de considerável quantidade de entorpecentes variados, principalmente a cocaína, substância de reconhecido potencial tóxico, e aqui condenados pelo crime autônomo de associação ao tráfico)” (fl. 150), elementos que, a toda evidência, justificam a fixação de regime mais gravoso do que o cabível em decorrência da reprimenda aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 676.646/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

Como cediço, na fase da denúncia vigora o princípio in dubio pro societatis da análise das provas e o I.P. é peça meramente informativa destinada tão-somente a autorizar o exercício da ação-penal. Todavia, na sentença, se das provas emergem dúvidas da autoria, aplica-se o princípio in dubio pro reo. Neste sentido:

“Inquérito Policial - Valor deste que não pode ser tamanho que autorize a condenação apenas com seus elementos - Prova suficiente para o oferecimento da denúncia, mas não para a condenação - Absolvição mantida” (Relator: Renato Nalini - Apelação Criminal 94.764-3 - Mauá - 25.03.91).

“Inquérito policial - Natureza - Disciplina da Prova - O inquérito policial constitui mero procedimento administrativo, e de caráter investigatório, destinado a subsidiar a atuação do Ministério Público. Trata-se de peça informativa cujos elementos instrutórios - precípuamente destinados ao órgão da acusação pública - habilitá-lo-ão a instaurar a persecutio criminis in judicio. A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela Polícia Judiciária na fase preliminar da persecução penal (informatio delicti) e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito. A investigação policial - que tem no inquérito o instrumento de sua concretização - não se processa, em função de sua própria natureza, sob o crivo do contraditório, eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade e da instrução criminal contraditória. A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina como pela jurisprudência dos Tribunais (RT 522/396), cujo magistério

tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo. Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia" (STF - 1ª Turma - REcr. nº 136.239-1/SP - RELATOR:- Min. Celso de Mello - DJU 14/08/92, pág. 12227).

Conclui-se, pois, pela parcial procedência com a consequente condenação de Maximiliano Moura Ramos e Edilson César Nunes Coelho por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Não agiram com intensidade dolosa incomum para os delitos da espécie, razão pela qual sua pena base observará o mínimo legal.

Maximiliano faz jus à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Entretanto, como é cediço, ao Magistrado não é dado transgredir os limites que a lei fixa para as penas, salvo nos casos em que tal faculdade é expressamente outorgada. Assim, inadmissível é a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda quando se cuide de agente confesso judicialmente:

"Na aplicação da pena, as circunstâncias atenuantes, de consideração obrigatória, não permitem a fixação da reprimenda em parâmetros inferiores ao mínimo legal, não havendo confundi-las com as causas de diminuição de pena, que, estas sim, ensejam essa possibilidade" (RJD 23/299).

É de se observar que a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça não revogou sua Súmula 231. A atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal continua não tendo o condão de reduzir a reprimenda para abaixo do mínimo legal. Neste sentido, inclusive, já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE SEM REFLEXOS NA PENA. SÚMULA 231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - De acordo com o enunciado n. 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal". III - In casu, a forma da confissão da paciente, para se beneficiar de tese da defesa, configura confissão qualificada, de modo que foi expressamente confirmado pelo juiz de origem que a paciente admitiu a imputação dos fatos relativos ao dia 06/01/2016. IV - Destarte, considerando a utilização da confissão para formara convicção do julgador, deve ela ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, considerando que a pena-base da paciente foi fixada no mínimo legal, "[n]os termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 623.682/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/10/2015). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão na dosimetria, sem reflexos na pena definitiva (Súmula 231 STJ), mantidos os demais termos da condenação" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 431.336-RS. Relator: Ministro Felix Fischer. Julgamento: 12 de junho, 2018. Publicação: 15 de julho, 2018).

São tecnicamente primários.

É pertinente a redução prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.887.511-SP, que fixou diretrizes acerca da consideração da quantidade e variedade de entorpecentes na dosimetria da pena.

"PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU

MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira. 4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos – necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença” (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

Assim, tratando-se de agentes primários, a redução deve se dar em seu grau máximo, ou seja, 2/3, conforme o preconizado pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Considerando os parâmetros acima e os demais critérios preconizados pelo artigo 59, do Código Penal:

Maximiliano Moura Ramos: fixo a pena-base em mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na base. Pela incidência do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Deixo de aplicar a atenuante da confissão, posto que a pena já se encontra em seu patamar mínimo legal para a fase, de acordo com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, sendo que a reprimenda não pode ficar aquém de seu mínimo legal. Não há outras atenuantes ou agravantes. Reconhecida a aplicação do § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, reduz a pena em 2/3, resultando em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis dias) dias-multa, calculados na base. Não há outras causas de diminuição ou de aumento;

Edilson César Nunes Coelho: fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na

base. Não há atenuantes ou agravantes. Reconhecida a aplicação do § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, reduz a pena em 2/3, resultando em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados na base. Não há outras causas de diminuição ou de aumento.

À míngua de outras causas legais de alteração torno esta pena definitiva.

Em face do disposto no artigo 33, alínea c, do Código Penal e artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fixo o regime inicial aberto. Por força da Resolução 5/2012 do Senado Federal, não havendo óbice, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo nacional à A.A.C.D./Osasco-SP e prestação de serviços à comunidade por igual prazo. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO MAXIMILIANO MOURA RAMOS e EDILSON CÉSAR NUNES COELHO, qualificados nos autos, a cumprirem, em regime inicial aberto, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo nacional à A.A.C.D./Osasco-SP e prestação de serviços à comunidade por igual prazo, por incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO-OS da imputação do artigo 35, da Lei 11.343/06 e do artigo 14, da Lei 10.826/03.

Considerando o quantum da reprimenda aplicada a Maximiliano e Edilson César, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para ambos, poderão recorrer em liberdade. Expeçam-se, de imediato, os respectivos alvarás de soltura clausulado.

Detração penal deverá ser aplicada pelo Juízo da Execução Criminal, ante à concessão de recurso em liberdade.

No mais, autorizo a destruição do entorpecente nos termos regimentais, bem como do aparelho telefone celular.

Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P. I.C.

Osasco, 20 de outubro de 2022.